

1503915-80.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503915-80.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503915-80.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2047209/2020 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 10106815 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 495/20/358 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2047209 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 495/20/358 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 2047209 - 95º D.P. HELIÓPOLIS, 495/20/358 - 95º D.P. HELIÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ISAAK BERNARDO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

ISAAK BERNARDO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Isso porque, No dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 16h30min, na Rua Siqueira Bulcão, nº 325, Ipiranga, nesta Capital, foi preso em flagrante quando trazia consigo, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 35,9g (trinta e cinco gramas e nove decigramas) de cocaína, distribuída em 43 invólucros plásticos; 35,8 (trinta e cinco gramas e oito decigramas) de Cannabis sativa L, conhecida como "maconha", erva que contém a substância Tetrahydrocannabinol, distribuída em 30 invólucros

plásticos.

Policiais Civis, investigando local conhecido como ponto de tráfico de drogas, viram o denunciado parado na rua, portando uma "pochete", e deliberaram abordá-lo. O denunciado tentou fugir, mas tropeçou, caiu e foi alcançado pelos Policiais. Dentro da "pochete" que o denunciado portava os Policiais encontraram as drogas mencionadas e papéis com anotações relativas à contabilidade do tráfico. As drogas foram apreendidas (fls. 8/9). Laudo de constatação constatou tratar-se de substâncias ilícitas (fls. 23/26;98/100).

A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes (várias porções, em embalagens próprias para o comércio) e as circunstâncias da prisão (agente, surpreendido com anotações relativas ao tráfico, que confessa informalmente o delito aos Policiais) indicam que as drogas se destinavam ao comércio.

Oferecida a denúncia (fls.1/3), foi ela recebida no dia 25 de março de 2020 (fls.78/79). O acusado foi citado (fls.91), vindo aos autos, no prazo legal, a defesa prévia (fls.60/61), subscrita pela defesa constituída. Inviável a absolvição sumária, designei audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de outubro de 2022, às 14:30 horas (fls.143/144), na modalidade presencial.

Durante a instrução da causa duas testemunhas foram ouvidas. O réu não foi interrogado porque não compareceu ao ato, tendo sido decretada sua revelia.

Encerrada a instrução criminal e superada a fase do 402, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denuncia e a não aplicação da minorante do artigo 33, §4º da lei de Drogas diante do passado infracional do acusado e regime fechado. Requereu a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento das cautelar de comparecimento aos autos processuais.

A Defesa, por sua vez, requereu, em caso de condenação, a aplicação da minorante previsto pelo artigo 33, §4º da Lei de Drogas, redução máximo, regime aberto e recurso em liberdade.

Encontram-se, ainda, nos autos, o auto de prisão em flagrante (fls.4); o boletim de ocorrência (fls.5/7); o auto de exibição/apreensão (fls.8/9); o auto de qualificação (fls.10); o termo de depoimento (fls.12;15); o laudo de constatação provisória, (fls. 23/26) e o laudo químico-toxicológico, (fls. 98/100).

E o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a ação penal porque, ao cabo da instrução criminal restou perfeitamente delineada a autoria e a materialidade do crime tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 conforme mais adiante se verá.

Com efeito, a materialidade delitiva foi aferida pelo teor do auto de exibição e apreensão (fls. 8/9 ) e dos laudos de constatação provisória (fls. 23/26), bem como pelo laudo toxicológico definitivo de substancia entorpecente (fls. 98/100), com resultados positivos para COCAÍNA e TETRAHIDOCANNABINOL (THC).

A autoria do delito, por seu turno, foi evidenciada pelo conjunto da prova oral colhida no curso da ação penal e pelos demais informes colhidos na fase inquisitiva, vejamos.

Adiel, policial civil, declarou que recordou-se dos fatos. No momento em que efetuou a prisão, ele disse que a sacola não era dele, mas estava em posse dele. Na pochete, umas 40 porções de cocaína e umas 30 de maconha. No dia estavam com uma mini operação da Delegacia no combate ao trafico. Estava no 95 DP. Isaak estava parado em uma viela com a pochete. Não se recorda se ele estava com mais alguém. Não se recorda se chegou a vê-lo em atitude de mercancia. O fato é que viram o acusado com a pochete que tentou fugir ao perceber que era um policial. Acredita que ao pega-lo a pochete pode ter caído mas afirma que ao vê-lo em um primeiro momento ele estava com ela nas mãos. Os fatos ocorreram de dia. Ele acabou admitindo que estava vendendo drogas, não se recorda se havia dinheiro. Não se recorda se ele morava no local dos fatos. As drogas estavam fracionadas para venda. Dentro da pochete havia anotações típicas de trafico. Não o conhecia antes dos fatos. Não chegou a perde-lo de vista á poca dos fatos.

Anderson, o outro policial, recorda-se dos fatos até porque o local da ocorrência

trata-se de um local difícil para a incursão policial. Viram o acusado em um corredor dentro da comunidade na posse de uma pochete. Ele tentou fugir assim que notou que eram policiais. A ideia era combater o tráfico em Heliópolis que é muito grande. Então estavam obedecendo as ordens. Dentro da pochete eram maconha e cocaína já fracionadas para a venda. Havia, ainda, anotações típicas de tráfico. No momento em que visualizou o acusado ele já estava com a pochete.

Como se vê, o quadro probatório é sólido e não deixa dúvidas acerca da conduta delituosa do acusado. Os elementos de convicção colhidos na fase policial e em juízo revelam-se firmes e substanciais, apontando-o com segurança como agente criminoso, no caso vertente.

E, embora os fatos tenham ocorrido há algum tempo, os policiais conseguiram se recordar da prisão sendo certo que seus depoimentos prestados em juízo são harmônicos com o que foi dito por eles ainda na fase extrajudicial.

É sabido que no processo penal por tráfico normalmente a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, que efetivam a apreensão da droga. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel.Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel.Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido ainda:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

Daí porque, confrontados os elementos de prova, afigura-se de rigor a condenação. Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Isto porque, a meu sentir, não há razões para que a pena base seja aumentada além do mínimo já que os tipos de entorpecente apreendidos em posse dele bem como a quantidade, não desbordam do que ordinariamente já está previsto no tipo penal. Portanto, quanto a este aspecto, discordo da posição trazida pelo Ministério Público.

Em segunda fase, nada a considerar.

Em terceira fase, pesem as ponderações trazidas pelo Ministério Público, entendo que é o caso de aplicação do tráfico privilegiado, ou seja, a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. O réu é primário e não possui maus antecedentes, fls.33. Não se pode presumir, de outra banda, que ele se dedicava à atividade criminosa de forma habitual ou, ainda, que integrasse organização criminosa apenas porque estivesse na posse de 72 gramas de entorpecente, ainda que em sua forma variada. Só é viável o afastamento da benesse se a condição de reincidente ou portador de maus antecedentes, bem como de integrante de organização criminosa ou delinquente habitual, restarem devidamente comprovadas. Não basta que tenha sido preso em flagrante por tráfico para se atribuir ao réu a prática de atividades criminosas que impeçam a redução da pena. É necessário que dos autos, ou das circunstâncias da prisão, sobressaiam elementos indicativos de outras atividades ilícitas que não o próprio tráfico em si. E a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante do tráfico

privilegiado, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Como disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e visam à proteção integral do adolescente infrator. Neste sentido, com base em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, da qual colhe-se que a jurisprudência vem se encaminhando no sentido de não admitir que atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas anteriormente cometidos pelo agente sejam aptos a caracterizar maus antecedentes ou dedicação a atividades criminosas, para o efeito de impedir a minorante do tráfico privilegiado, HC n. 199.060/SP, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26/3/2021, cito recebte acórdão do Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HABEAS CORPUS Nº 724495 - SP (2022/0046041-0) Relator : Ministro Sebastião Reis Júnior . E, seguido-se esse entendimento, no caso em apreço, a carga redutora a ser aplicada, considerando-se as circunstancias do caso concreto, é a máxima, ou seja, 2/3.

Assim sendo, diminuo a pena anteriormente aplicada em 2/3 (dois terços), com o que a reprimenda privativa de liberdade resulta em 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida. Fixo o REGIME ABERTO para início de cumprimento da pena pois entendo ser suficiente a, no caso concreto, coibir a pratica delitiva.

Por fim, estabeleço o regime aberto para cumprimento da reprimenda. Isto porque, apesar de o art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90 determinar a fixação de regime inicial fechado para cumprimento do delito de tráfico de entorpecentes, por equipará-lo a hediondo, esta previsão não se aplica ao tráfico privilegiado. Como cediço, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de que o delito de tráfico de drogas, quando há o reconhecimento do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 1.343/06, não é equiparado a hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/90, conforme se depreende do teor da seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida” (Habeas Corpus nº 118.533/MS - Tribunal Pleno- Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 23.06.2016).

No mesmo sentido, os recentes Habeas Corpus nº 136.545, de relatoria do Min. Celso de Mello, j. 07.10.2016; nº 136.762, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, j. 06.10.2016; e Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 937.651, de relatoria do Min. Roberto Barroso, j. 09.09.2016.

Consequentemente, concedo o apelo em liberdade.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação e condeno ISAAK BERNARDO DE SOUZA, RG: 55051926, CPF: 439.092.348-01, nascido em 31/10/2000, natural de São Paulo - SP, filho de Sebastiao Bernardo de Souza Filho e Simone Santana de Souza, como incurso nas sanções do art. 33, “caput” e § 4º da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Outrossim, não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho meu entendimento no sentido da

impossibilidade da referida conversão.

Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, até porque a conversão das penas privativas de liberdade não é automática, devendo o Magistrado analisar os preceitos estabelecidos do Código Penal.

No presente caso, temos que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao réu, que claramente praticava o comércio de drogas é insuficiente para a prevenção e repressão do delito, sendo, portanto, sua concessão, vedada pelo art. 44, inciso III, e 77, II, ambos do Código Penal.

O réu praticou crime gravíssimo, sendo com ele apreendido drogas de alto potencial lesivo, droga esta capaz de atingir a um sem-número de usuários e viciados. Assim, pelas circunstâncias concretas do crime, não há indicação de que tal substituição ou seja suficiente ou recomendável.

Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Transitada em julgado, determino as providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c.c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Transitada esta em julgado tornem conclusos para a designação de data para audiência admonitória.

Publicada em audiência.

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA